

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5197/2549

นางสาวแคลร์-ลีส บูจอง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (3), มาตรา 11 วรรคสอง,
มาตรา 80

อักษรโรมันคำว่า CREATING - CONCEPT เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกัน
ย่อมแปลได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ แม้จะมีเครื่องหมายยัติภังค์คั่นอยู่ตรงกลางของ
คำทั้งสองก็ไม่ทำให้คำทั้งสองซึ่งมีความหมายอยู่แล้วกลายเป็นคำไม่มีความหมายไป
ได้ เมื่อเป็นคำที่มีความหมายอยู่แล้วจึงมิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้นและไม่มีลักษณะบ่ง
เฉพาะตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (3) ประกอบ
มาตรา 80 อย่างไรก็ดีตาม คำที่มีใช้คำที่ประดิษฐ์ขึ้นอาจเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้
หากคำนั้นมีได้เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรง แต่บริการ
ของโจทก์ตามรายการบริการในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการส่วนใหญ่เกี่ยว
กับการเสนอความคิดให้แก่ลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ คำว่า CREATING - CONCEPT จึง
เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการของโจทก์โดยตรง

แม้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกหรือ
องค์การการค้าโลกจะรับจดทะเบียนคำว่า CREATING - CONCEPT การจดทะเบียนดัง
กล่าวก็ไม่มีผลผูกพันนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย เพราะแม้
ประเทศไทยจะเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศทั้งสอง แต่การจดทะเบียน

เครื่องหมายบริการย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศที่จะวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร และความเห็นของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้น ๆ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.

เครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 11 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80

ส่วนการดูไบหน้าคล้ายรูปไข่หลับตาและยิ้ม มีลักษณะท่าทางเหมือนกำลังก้าวเดินขึ้นไปบนสายรุ้ง และที่ปลายสายรุ้งมีรูปพระจันทร์เสี้ยวอันเป็นภาพที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้น เครื่องหมายบริการในส่วนนี้จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ ดังนั้น เครื่องหมายบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียน หากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้วมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ แต่เครื่องหมายบริการดังกล่าวมีส่วนหนึ่งคือคำว่า **CREATING - CONCEPT** มีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ จึงให้โจทก์ละสิทธิที่จะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 2 ที่สั่งให้โจทก์ละสิทธิที่จะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมัน คำว่า **CREATING - CONCEPT** และมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยและมติของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ที่มีคำวินิจฉัยและมีมติให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 441921 คำขอเลขที่ 441922 และคำขอเลขที่ 441923 และมีคำสั่งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำเลยที่ 1 และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 2 ดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 441921 คำขอเลขที่ 441922 และคำขอเลขที่ 441923

จำเลยทั้งสิบสามให้การขอให้ยกฟ้อง

ในการชี้สองสถาน ศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพียงข้อเดียวโดยให้โจทก์นำสืบก่อนว่า คำสั่งของจำเลยที่ 2 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 1 เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 441921 คำขอเลขที่ 441922 และคำขอเลขที่ 441923 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า อักษรโรมันคำว่า CREATING - CONCEPT ทั้งนายอนุชัย พยานโจทก์และนายวัชระ พยานจำเลยทั้งสิบสามต่างเบิกความว่า คำว่า CREATING แปลว่า สร้างสรรค์ ส่วนคำว่า CONCEPT แปลว่า ความคิด เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกันย่อมแปลได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ แม้จะมีเครื่องหมายยัติภังค์คั่นอยู่ตรงกลางของคำทั้งสองก็ไม่ได้ทำให้คำทั้งสองซึ่งมีความหมายอยู่แล้ว กลายเป็นไม่มีความหมายไปได้ เมื่อคำทั้งสองเป็นคำที่มีความหมายอยู่แล้ว คำทั้งสองจึงมิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้น คำทั้งสองจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 อย่างไรก็ตาม คำที่มีใช้คำที่ประดิษฐ์ขึ้น อาจเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน หากคำนั้นมิได้เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรงและไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด แต่บริการของโจทก์ตามรายการบริการในคำขอจดทะเบียน

เครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.15 ถึง จ.17 ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเสนอความคิด ให้แก่ลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ คำว่า CREATING - CONCEPT จึงเป็นคำที่เล็งถึง ลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการของโจทก์โดยตรง คำดังกล่าวจึงเป็นคำที่ไม่มี ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราช บัญญัติฉบับเดียวกัน ส่วนที่โจทก์อ้างว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์ได้ใช้กับบริการ ของโจทก์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และโฆษณาเผยแพร่ทั่วไปตามเอกสารหมาย จ.2 ถึง จ.7 เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะนั้น เห็นว่า คำที่ไม่มี ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราช บัญญัติฉบับเดียวกันจะเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม ประกอบ มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันต่อเมื่อมีการจำหน่ายเผยแพร่หรือ โฆษณาสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดและพิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติถูกต้องตาม หลักเกณฑ์นั้นแล้ว หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดนั้น ได้แก่ หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ลงวันที่ 23 กันยายน 2542 ข้อ 2 ซึ่งระบุว่า การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม จนแพร่หลายแล้วตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือ โฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้า หรือบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการอื่น

(2) การจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการใดจนทำให้เครื่องหมายการค้ามีความแพร่หลายในประเทศไทย ให้ถือว่าเครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงที่ใช้กับสินค้าหรือบริการนั้นเท่านั้น

(3) ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตาม (1) และ (2) ให้ผู้จดทะเบียนยื่นนำส่งพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาในประเทศไทยซึ่งสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ตัวอย่างสินค้า ใบโฆษณาสินค้า หรือพยานหลักฐานอื่น ๆ รวมทั้งพยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น

(4) ในการส่งหลักฐานตาม (3) ให้ผู้จดทะเบียนส่งหลักฐานพร้อมการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายทุกคำขอ ในกรณีที่ไม้อาจกระทำได้ ให้ผู้จดทะเบียนทำหนังสือขอผ่อนผันแนบมาพร้อมคำขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนมีอำนาจผ่อนผันได้ไม่เกิน 30 วัน ถ้าผู้จดทะเบียนมิได้ส่งหลักฐานใดภายในกำหนดเวลาที่นายทะเบียนผ่อนผันให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการแก้คำขอจดทะเบียนนั้นต่อไป โดยรับฟังข้อเท็จจริงเพียงเฉพาะหลักฐานเท่าที่ผู้จดทะเบียนได้ส่งให้แก่ นายทะเบียนไว้ (ถ้ามี)

ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโจทก์ซึ่งเป็นผู้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการจะต้องพิสูจน์ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่นจึงจะถือว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่โจทก์คงมีแต่พยานหลักฐานว่ามีการโฆษณาบริการตามเครื่องหมายบริการของโจทก์เท่านั้น โจทก์มิได้นำสืบพิสูจน์ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนใน

ประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่น ฉะนั้น คำว่า CREATING - CONCEPT ซึ่งเป็นเครื่องหมายบริการของโจทก์ จึงมีใช้คำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องจากการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรึว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดตามมาตรา 7 วรรคสาม ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเคยรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า TACITLY CREATION และ City Concept ก็จะนำการรับจดทะเบียนดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับคำขอจดทะเบียนของโจทก์ไม่ได้ เพราะการจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้า มิใช่การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเพื่อใช้กับบริการเหมือนโจทก์ ทั้งคำดังกล่าวก็มีได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ขอจดทะเบียนโดยตรง แม้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization หรือ WIPO) หรือองค์การค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แคนาดา อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ จะรับจดทะเบียนคำว่า CREATING - CONCEPT ตามที่โจทก์อ้าง การจดทะเบียนดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย เพราะแม้ประเทศไทยจะเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศทั้งสองแต่การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศที่จะวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร และความเห็นของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้น ๆ ไม่อาจนำมาเป็นเหตุผลให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ทั้งมาตรา 11 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพียงแต่บัญญัติว่า ในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ

คุ้มครองเครื่องหมายการค้า หากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปตามที่
กำหนดในอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว ให้ถือว่าคำขอดังกล่าว
เป็นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ บทบัญญัตินี้หาได้
บัญญัติให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการนั้น
โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ฉะนั้น นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าจึงมีอำนาจรับจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
ของโจทก์ ถ้ารับจดทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ก็ได้
ปรากฏว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์มิได้มีแต่คำว่า CREATING - CONCEPT
เท่านั้น แต่ยังประกอบด้วยการ์ตูนใบหน้าคล้ายรูปไข่หลับตาและยิ้ม มีลักษณะ
ทำทางเหมือนกำลังก้าวเดินขึ้นไปบนสายรุ้ง และที่ปลายสายรุ้งมีรูปพระจันทร์เสี้ยว
อันเป็นภาพที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้น เครื่องหมายบริการในส่วนนี้จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ
ตามมาตรา 7 วรรคสอง (6) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน
ฉะนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นด้วย
กับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 ที่เห็นว่าเครื่องหมายบริการที่โจทก์ขอ
จดทะเบียนหากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้วมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตาม
มาตรา 6 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน แต่เครื่องหมาย
บริการดังกล่าวมีส่วนหนึ่งคือคำว่า CREATING - CONCEPT มีลักษณะไม่บ่ง
เฉพาะ จึงให้โจทก์สิทธิที่จะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำดังกล่าว
กับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอเอกสารหมายเลข จ.15 ถึง จ.17 ตาม
มาตรา 17 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ดังนั้นคำสั่งของ
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 ตามเอกสารหมายเลข จ.18 ถึง จ.20 จึงเป็น
คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ตามเอกสารหมายเลข จ.30 ถึง จ.32 ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย เพราะมิใช่กรณีที่เครื่องหมายบริการของโจทก์ทั้งเครื่องหมายหรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจด
ทะเบียนได้ตามมาตรา 16 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน แต่
เป็นกรณีตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันดัง
กล่าวมาแล้ว ฉะนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
พิพากษามานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึง
เห็นด้วยบางส่วน อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของ
โจทก์คำขอเลขที่ 441921 เลขที่ 441922 และเลขที่ 441923 ให้บังคับไปตามคำสั่ง
ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 ที่ให้โจทก์สละสิทธิที่จะไม่ขอถือเป็น
สิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า CREATING - CONCEPT กับให้นาย
ทะเบียนรับดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป ค่า
ฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับทั้งสองศาล.

(ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม-สุวัฒน์ วรธนะหทัย-ปัญญารัตน์ วีระยะวานิช)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายภาณุ รังสีลภัส

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ